

1082632-91.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Contratos Bancários

Magistrado: Luiz Gustavo Esteves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 11ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... por volta das 20h, foi vítima de um furto, no qual lhe foi subtraído, fls.

21/23; (c) que no mesmo dia foi realizada uma contratação de empréstimo para quitar os anteriormente firmados, fls. 24/25; (d) que houve comunicação do furto ao banco. Pois bem.

A responsabilidade da prestadora de serviços aos consumidores é objetiva, aplicando-se-lhe, nesta medida, o disposto no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO -Foro Central Cível

11ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, 12º andar, sala 1220, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)

3538-9247, São Paulo-SP - E-mail: upj11a15cv@tjsp.jus.br

C O N C L U S ã O

Em 28 de novembro de 2022 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). Luiz Gustavo Esteves. Eu _____ (Luiz Gustavo Esteves), Juiz de Direito, subscrevi.

S E N T E N Ç A

Processo nº:

1082632-91.2022.8.26.0100

Classe – Assunto:

Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários

Requerente:

Elidaiane Conceição dos Santos

Requerido:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Vistos.

ELIDAIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ingressou com a presente ação desconstitutiva c/c indenizatória em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ambos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese, que é correntista junto ao requerido; que no dia 24/03/2022, ao sair da sua academia, foi surpreendida por terceira pessoa que subtraiu seu celular; ao retornar para sua residência, cancelou o chip do seu celular; consultando sua conta bancária, tomou conhecimento que os empréstimos que possuía foram renegociados; aparentemente, o meliante tentou obter um empréstimo em seu nome, mas, acabou por renegociar aqueles já existentes; que possuía três empréstimos com o requerido; com a renegociação, houve a consolidação em um novo empréstimo; que tentou resolver a questão de forma administrativa, sem sucesso; que sofreu danos morais. Assim, pretende com a presente demanda o restabelecimento de sua situação junto à instituição financeira do dia anterior à prática criminosa, além da condenação pelos supostos danos morais causados.

A inicial de fls. 01/17 veio instruída com documentos.

Emenda à inicial a fls. 91/102.

Pedido de tutela deferido a fls. 105.

Citado, o requerido ofertou resposta na forma de contestação, fls. 111/127, com documentos, alegando, em resumo, que não foram identificadas quaisquer irregularidades nas transações questionadas, as quais foram realizadas regularmente por meio da posição do código do dispositivo de segurança (CS0) e digitação de senha pessoal; que o evento ocorrido se trata de fortuito externo; culpa exclusiva da autora; que as transações estavam dentro do perfil da autora; que a comunicação dos fatos se deu apenas dois dias dos eventos; inexistência de danos indenizáveis; pela improcedência.

Réplica a fls. 202/205.

Instadas a produzir provas, as partes se manifestaram.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Inicialmente, convém pontuar que a relação travada entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297, do STJ.

Restou incontroverso nos autos que (a) a autora é correntista junto ao requerido, (b) que no dia 24/03/2022, por volta das 20h, foi vítima de um furto, no qual lhe foi subtraído, fls. 21/23; (c) que no mesmo dia foi realizada uma contratação de empréstimo para quitar os anteriormente firmados, fls. 24/25; (d) que houve comunicação do furto ao banco.

Pois bem.

A responsabilidade da prestadora de serviços aos consumidores é objetiva, aplicando-se-lhe, nesta medida, o disposto no artigo 14, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e Súmula 297, STJ.

A teoria sob a qual sua atuação deve ser analisada é, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva, que, embora independa de culpa, bastando o fato danoso, exige como pressuposto à responsabilização, o nexo causal.

A regularidade das operações discutidas nos autos não foi comprovada pelo réu, tratando-se de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, inc. II, CPC).

Ora, não se desincumbindo de seu ônus probatório de comprovar a segurança dos serviços bancários, nem do repasse da senha de acesso pela parte autora, a responsabilidade da instituição financeira é inegável.

Assim, não tendo sido realizado pela parte autora as operações discutidas, o dever do banco restituir os valores indevidamente descontados é de rigor, assim como a declaração de sua inexigibilidade.

Sobre o tema, a Egrégia Corte Paulista:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOVIMENTAÇÕES EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - FURTO DE TELEFONE CELULAR - EMPRÉSTIMO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PAGAMENTO REALIZADOS POR FRAUDADOR - BANCO QUE AFIRMA O FORNECIMENTO DE DADOS A TERCEIROS UMA VEZ QUE A OPERAÇÃO OCORREU MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA E INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO TOKEN - TESE DA INFALIBILIDADE DO SISTEMA DESCARTADA - SÚMULA Nº 479/STJ - DANOS MORAIS - SITUAÇÃO QUE PODERIA CARACTERIZAR SIMPLES ABORRECIMENTO COTIDIANO - NEGATIVA DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROCUROU SOLUCIONAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MAXIMIZAÇÃO DO SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA CONSUMIDORA - ELEVADO O DANO A PATAMAR INDENIZÁVEL - REPARAÇÃO REDUZIDA PARA R\$ 10.000,00, VALOR QUE BEM EQUACIONA O ABALO SOFRIDO, O CARÁTER PEDAGÓGICO E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, ATENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SÚMULA Nº 326/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009314-02.2018.8.26.0008; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais - Fraude no sistema "internet banking" - Banco que responde não só pela segurança das ferramentas disponibilizadas em ambiente virtual, bem como pelo sigilo das informações pessoais de seus clientes - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Excludente de responsabilidade não comprovada - Danos materiais devidos - Danos morais não configurados - Ação de

ressarcimento de danos materiais e morais parcialmente procedente - Apelação provida em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1049089-03.2017.8.26.0576; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferência de valores por meio de aplicativo de celular não reconhecida pela parte autora. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Atuação de terceiro fraudador que restou incontroversa. Ônus da prova carreado à parte ré, que não demonstrou ter a parte autora agido com desídia em relação a seus dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Dano material que deve ser ressarcido. Falha na prestação de serviço. Retirada de valores de poupança, cujo saldo foi zerado. Dano moral igualmente configurado. 'Quantum' indenizatório dos danos morais reduzido para R\$5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta Câmara. Honorários recursais que não se aplicam, 'in casu', ante o acolhimento em parte do recurso. Recurso provido em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1002803-88.2017.8.26.0568; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018)

A alegação de fato de terceiros não merece prosperar.

A contratação por fraudador de serviços ou aquisição de produtos fornecidos pela ré em nome do(a) autor(a) configura verdadeiro defeito na prestação de serviços ao consumidor.

Ademais, cuida-se de risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC).

Sob outro aspecto, o fato de terceiro capaz de excluir a responsabilidade do fornecedor de serviços é qualificado como exclusivo, nos termos do §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor:

"(...)§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." [g.n.]

Não há culpa exclusiva na hipótese em que o próprio fornecedor, por incompetência ou precariedade nos sistemas de segurança, fornece serviços ou entrega produtos não contratados pelo consumidor.

Ademais, cuidar-se-ia de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do fornecedor.

Sobre o tema, Agostinho Alvim afirma que o fortuito interno é ligado à própria atividade geradora do dano, ou à pessoa do devedor e, por isso, leva à responsabilidade do causador do evento. Somente o fortuito externo, ou força maior, é que exoneraria o devedor, mas exigiria fato externo, que não se liga à pessoa ou empresa por nenhum laço de conexidade (Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, São Paulo: Saraiva, 1949, p. 291).

A matéria foi pacificada, inclusive, pela Súmula 479, do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O mesmo diga-se acerca da culpa concorrente da vítima, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços.

Desse modo, a operação realizada deve ser declarada inexigível, bem como os descontos realizados a esse título na conta da autora.

Dessa forma, por todos os ângulos, a única vítima inocente é a parte autora.

O pedido de danos morais prosperam.

Neste particular, são esclarecedoras as palavras do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como da nominal a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Programa de Responsabilidade Civil. ed. 8ª São Paulo: Atlas, p. 83/84).

Ora, a conduta ilícita (art. 186, CC) invasora da intimidade da pessoa humana, atentando contra seu sigilo bancário, desassossegando o seu coração pela rapina de seu salário ou benefício gera, inegavelmente, transtornos que transbordam da normalidade, na medida em que nenhuma relação jurídica há entre as partes que autorize uma a apropriar-se de valores da outra ou deles dispor em favor de criminosos.

É indisputável o dever de indenizar os danos morais, sendo hipótese de dano in re ipsa.

Sobre o tema, confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL - BANCO - CARTÃO MAGNÉTICO - SAQUE INDEVIDO - DEFEITO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CASO EM QUE INCUMBIA AO RÉU O ÔNUS DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA OU DE TERCEIRO - RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA AO CONSUMIDOR - REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL CABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Sumaríssima 9259950-22.2008.8.26.0000; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª VC F Reg Penha de Franca; Data do Julgamento: 16/07/2008; Data de Registro: 29/07/2008)

Dessa forma, resta apenas fixar o quantum debeatur.

A propósito do arbitramento da indenização, deve o Juiz pautar-se em um papel compensatório para a vítima e, ao mesmo tempo, desestimulante ao ofensor (ou seja, o causador do dano deve ser apenado com um importe que o faça pensar antes de repetir a conduta).

Embora a Teoria do Desestímulo não seja expressa no Código Civil, existe projeto de reforma legislativa para acrescentá-la ao artigo 944 do Código Civil.

Pese a omissão legislativa, a doutrina não diverge sobre a dupla função da indenização moral.

De fato, tem-se decidido que, para a fixação do montante da indenização, devem ser levados em conta os seguintes parâmetros:

"A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de modo que tampouco signifique enriquecimento despropositado da vítima; mas está também em produzir no agressor, impacto bastante para persuadi-lo a não perpetrar novo atentado. Trata-se então, de uma estimativa prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados d'alma humana, e que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por outro jurista - inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em economia. É nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia, aponta elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social e reputação), gravidade da falta e da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e a personalidade (condições) do autor do ilícito" (Essa Inexplicável Indenização por

Dano Moral, Des. Walter Moraes, Repertório IOB de Jurisprudência, nº 23/89, p. 417).

Procedendo à convergência dos caracteres consubstanciadores da reparação pelo dano moral, quais sejam: i) punitivo e profilático, para que as causadoras do dano, pelo fato da condenação, sejam castigadas pela ofensa perpetrada, bem assim intimidadas a se conduzirem de forma diligente no exercício de seu mister; e ii) compensatório, para que a vítima receba uma soma de dinheiro que lhe proporcione prazeres como contrapartida pelo mal sofrido, o valor da indenização deve ser fixado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O valor adotado leva em conta a profissão da autora, o montante movimentado em sua conta, e a grave desídia do réu que, mesmo percebendo a fraude e bloqueando a conta, não reconheceu a falha em seu sistema.

Anote-se que o valor pleiteado pela parte em sua petição inicial é meramente sugestivo, não implicando o seu acolhimento em montante inferior em sucumbência recíproca.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 326: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca." (Corte Especial, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006 p. 240)

A correção monetária deve incidir desde a data desta decisão, na forma do verbete nº 362, das Súmulas de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 362: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." (Corte Especial, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: i) DECLARAR inexigível a operação não reconhecida pela parte autora (Crédito Unificado com Proteção, fls. 24/25), confirmando-se a antecipação de tutela deferida nos autos; ii) CONDENAR a(o) ré(u) a restituir ao(à) autor(a) todos os valores indevidamente descontados de sua conta bancária, que guardem relação com a operação acima mencionada, com correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data de cada um dos descontos (art. 404, CC), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1º, CTN), desde a data do ato ilícito (art. 398 CC e S. 54, C. STJ), autorizada a compensação; (iii) CONDENAR o requerido a restabelecer os empréstimos anteriormente contratados pela autora e liquidados com a operação acima citada e mencionados a fls. 24, nos seus moldes originais e (iv) CONDENAR a(o) ré(u) a pagar ao(à) autor(a) indenização por danos morais consistente em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1º, CTN), desde a citação (art. 405 CC e 240, CPC).

O(A)s sucumbente(s) arcará(ão) com as custas e despesas processuais (art. 82, §2º, CPC), além de honorários advocatícios, desde já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, dada a pouca complexidade da demanda e do tempo decorrido, sem realização de audiência inclusive.

Nada sendo requerido no prazo de trinta dias contados do trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as comunicações devidas.

P.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

Luiz Gustavo Esteves

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA